

RELATOR – SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO JOSUÉ ROMERO

21ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno dia 21/08/2024

Exame Prévio Municipal

Julgamento

PROCESSO: TC 015760.989.24-4

REPRESENTANTE: ADRIANO DE SOUZA LUSTOSA (CPF ***.747.354-** e OAB/SP nº 442.805).

REPRESENTADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO (CNPJ 46.578.530/0001-12).

RESPONSÁVEL: ELEAZAR MUNIZ JUNIOR - PREFEITO

ADVOGADOS: FABRICIO ANDRADE DOS REIS (OAB/SP 250.417) / PAULO SERGIO DIAS SANTANA JUNIOR (OAB/SP 264.001).

ASSUNTO: Representação contra o edital do Pregão Eletrônico nº 08/2024, (Processo Administrativo nº 100/2024).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO.

Indevidas condições envolvendo: ausência de critérios objetivos, previamente, determinados para a respectiva avaliação de amostras; inobservância à Súmula nº 42 do E. TCE/SP devido à ausência de prazo suficiente para apresentação de laudo bromatológico; indevida solicitação das fichas e registros do item “9.16.10” do edital, em afronta à Súmula 15 do E. TCE/SP; e, requisição ilegal de motivação na fase de manifestação recursal, ora inexigível por força da Lei nº 14.133/21

RELATO REPRESENTAÇÃO FORMULADA POR ADRIANO DE SOUZA LUSTOSA VISANDO AO EXAME PRÉVIO DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.

Em síntese, o Representante impugnou:

- (i) carência imprópria da possibilidade de demonstração qualificação econômica, também, pela via do patrimônio líquido (e não só por capital social), em inobservância ao artigo 69, § 4º, da Lei nº 14.133/21;
- (ii) prazo exíguo para apresentação da amostra assim como ausência de critérios objetivos, previamente, determinados para a respectiva avaliação, além de inobservância à Súmula nº 42 do E. TCE/SP devido à ausência de prazo suficiente para apresentação de laudo bromatológico;
- (iii) favorecimento de certas proponentes (em detrimento da ampla competitividade), por conta da solicitação das fichas e registros do item “9.16.10” do edital, o que, ainda, implica à afronta à Súmula 15 do E. TCE/SP;
- (iv) ausência de justificativa para a estipulação do prazo de validade de itens da cesta básica; e
- (v) requisição ilegal de motivação na fase de manifestação recursal, ora inexigível por força da Lei nº 14.133/21

Após regular notificação, a Origem apresentou justificativas^[1], sustentando a higidez dos procedimentos e a regularidade do certame.

A ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA E SUA CHEFIA MANIFESTARAM-SE PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO^[2], IDÊNTICO POSICIONAMENTO ADOTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS E SDG ^[3].

É o relatório.

VOTO;

É infundado o inconformismo do Representante em relação ao critério eleito para demonstração de capacidade econômica das proponentes. A previsão de que seja realizado exclusivamente por meio de demonstração de valores do capital social é perfeitamente alinhada ao quanto expresso pelo artigo 69, § 4º, da Lei nº 14.133/21, que faculta ao Órgão Contratante a opção entre o capital ou o patrimônio líquido da licitante.

Trata-se de entendimento sedimentado nesta Colenda Corte de que a escolha se insere no campo discricionário de atuação do administrador público, consoante a própria decisão colacionada pelo Representante para fundamentar

sua objeção, proferida nos autos do TC-008882.989.24[4], que na realidade afasta a procedência da impugnação, *verbis*:

“Mesma sorte não assiste, por fim, à insurgência dirigida ao item 10, “c) 2” do edital, que cuida da comprovação da qualificação econômico-financeira exclusivamente através de capital social.

Acolho, nesse ponto, as conclusões do d. Ministério Público de Contas, para quem o artigo 69, § 4º, da Lei nº 14.133/21 estabelece prerrogativa ao administrador, para que discricionariamente estabeleça se o requisito de qualificação econômica ocorrerá pela via do capital social mínimo ou pela via do patrimônio líquido. Em se tratando de matéria afeta ao juízo de conveniência e oportunidade, seria inadequado censurar o emprego de apenas uma das hipóteses, consoante decidido pelo Plenário deste Tribunal nos autos dos TCs12646.989.23 e 12691.989.23.

Não obstante, tendo em vista que o dispositivo invocado não veda a conjugação das alternativas por ele discriminadas, não vejo razões para dissentir da recomendação proposta por MPC e SDG, no sentido de que o ente licitante avalie a pertinência de admitir as hipóteses de modo alternativo, a fim de propiciar maior competitividade ao certame”.

Todavia, sem embargo da improcedência da impugnação, conforme exposto pela decisão supracitada, cabe recomendação à Origem para que avalie a inclusão no instrumento convocatório a possibilidade de que a demonstração para fins de habilitação econômica possa também incidir sobre o patrimônio líquido das proponentes, de modo a ampliar a competitividade do certame.”

É igualmente improcedente a queixa relativa ao prazo estipulado de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de amostras, porquanto se trata de prazo razoável para apresentação de itens de prateleira, que compõem o objeto do presente certame em análise, e direcionada apenas à licitante vencedora, amoldando-se perfeitamente à jurisprudência desta Colenda Corte de Contas[5].

Entretanto, como bem exposto pelo D. Ministério Público de Contas, referido prazo mostra-se inadequado para a apresentação dos laudos bromatológicos, a exemplo da decisão proferida nos autos do TC-021208.989.18[6]:

“No tocante à documentação a ser apresentada juntamente com as amostras, interpreto como procedente apenas a questão relacionada à apresentação dos laudos bromatológicos, face à exiguidade do prazo estipulado no ato convocatório (8 dias) para a disponibilização dos referidos documentos.

Nesse sentido, confira-se a r. decisão exarada nos autos do processo n.º 17438.989.16-2, em Sessão Plenária de 08/02/2017, sob a relatoria do eminente Conselheiro Dimas Ramalho, em que prazo superior (10 dias) foi já considerado insuficiente, consoante trecho abaixo transcrito:

2.4 Ainda que, a priori, a exigência de laudos bromatológicos pareça se conformar ao entendimento deste Tribunal, eis que direcionada apenas ao

vencedor do certame, o prazo fixado para a apresentação do referido documento não se revela adequado a esse fim. A insuficiência do interregno concedido para obtenção daqueles documentos revela-se desestimulante e prejudicial à ampla competitividade, contrariando a regra do artigo 3º, §1º, inciso I, da Lei 8.666/93.

Destaco, sobre o tema, a decisão plenária de 15-06-2016, nos processos TC-9658.989.16-5 e TC-9659.989.16-4, Relator Conselheiro Renato Martins Costa:

“De outra parte, no que tange à exigência de laudos técnicos, verifico que a requisição está orientada somente ao vencedor da disputa, o que em princípio não destoaria da dicção da Súmula nº 14 deste Tribunal.

Entretanto, não afastando a prerrogativa discricionária da Administração, cumpre ressaltar que a dilação dos prazos para sua apresentação também deve ser observada. Assim, no ensejo da retificação, melhor que a Prefeitura igualmente reavalie se o prazo concedido é suficiente para obtenção dos documentos requeridos, bem como verifique a pertinência de dispensar a exigência de laudos para produtos já certificados pelo INMETRO, conforme entendimento exarado em casos assemelhados, a exemplo do TC-8125.989.16 (E. Tribunal Pleno, Sessão de 1º/6/16, relator o eminente Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo)”.

Assim, deve o edital ser retificado para conceder prazo razoável à obtenção dos laudos pretendidos.”

Procede, portanto, a Representação nesse quesito, devendo a Origem revisar o prazo concedido para a apresentação dos laudos bromatológicos.

Deve a Administração, da mesma forma, proceder à precisa delimitação dos critérios de avaliação das amostras de modo a assegurar o julgamento objetivo das propostas, tal como explicitado pelos demais órgãos pareceristas.

Procedente, outrossim, a insurgência em relação à exigência de apresentação de ficha técnica original ou cópia autenticada emitida pela empresa fabricante assinada pelo responsável técnico, já que, de fato, caracteriza compromisso de terceiro alheio à disputa, contrariando o disposto pela Súmula nº 15 deste Tribunal de Contas^[7].

Quanto à irresignação acerca das exigências editalícias referentes ao prazo de validade dos itens licitados, considero que é improcedente a reclamação, visto que foi exigido no instrumento convocatório apenas prazos mínimos de validade dos produtos, respeitadas as características de cada insumo, em plena consonância ao entendimento desta Egrégia Corte de Contas.

Ademais, os prazos estipulados não se demonstram desarrazoados ou destoam dos usualmente previstos no mercado, não se vislumbrando, assim, ter a Administração exorbitado de sua discricionariedade nas determinações previstas pelo edital.

Oportuno citar trecho do voto proferido nos autos do TC-002425.989.14^[8], que bem elucida a questão:

“2.4. As críticas formuladas em face da exigência de prazo máximo de fabricação – 90 dias, avaliadas em contraste com as plausíveis justificativas ofertadas pela Origem, exigem o direcionamento de uma solução intermediária, que preserve os legítimos interesses da Administração, mas que aproxime as disposições do edital às condições de aquisição e fornecimento semelhantes à do setor privado, exigência do art. 15, III da Lei 8.666/93, ampliando as condições de competitividade do certame.

É louvável e prudente que a Administração crie mecanismos destinados a prevenir o temerário fornecimento de cestas básicas contendo produtos na iminência de alcançar o prazo de validade.

No entanto, ao invés dos questionados prazos máximos de fabricação, apresenta-se como solução mais razoável a reformulação da cláusula impugnada de forma a impor prazos mínimos de validade dos produtos, preservando-se as condições de consumo por períodos adequados e de acordo com as necessidades de alimentação dos beneficiários.

Não há dúvidas de que os interesses e a preocupação externada na defesa mostram-se passíveis de serem atendidos mediante a fixação de prazo mínimo de validade contado da data do fornecimento, o qual deverá ser fixado dentro dos critérios da razoabilidade.

Portanto, meu voto considera procedente a impugnação apresentada neste tocante e determina que a Administração substitua a exigência de prazos máximos de fabricação por prazos mínimos de validade”.

Por fim, prospera o inconformismo do Representante em relação à exigência de apresentação dos motivos para a interposição do recurso administrativo.

Nesse sentido, acompanhando o entendimento dos órgãos pareceristas preopinantes, compreendo que a norma vigente estabelece que há apenas a necessidade de declinar a intenção de recorrer, sendo desnecessário expressar a motivação. Oportuno citar a respeito do tema a lição do Ilustre Professor Marçal Justen Filho “As razões recursais serão deduzidas em momento oportuno, não sendo necessário que o sujeito indique, de imediato, os fundamentos específicos de seu recurso”^[9].

Ante o exposto, VOTO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRESENTE REPRESENTAÇÃO, COM PROPOSTA DE DETERMINAÇÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO PARA QUE ADOTE AS MEDIDAS CORRETIVAS PERTINENTES QUE VIABILIZEM O ADEQUADO SEGUIMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBSERVANDO RIGOROSAMENTE A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA, O REPERTÓRIO DE SÚMULAS E A JURISPRUDÊNCIA DESTA TRIBUNAL, BEM COMO PROVIDENCIANDO A REPUBLICAÇÃO DO NOVO TEXTO E A REABERTURA DO PRAZO LEGAL.

Oportunamente, deve o processo, após a publicação do acórdão e o trânsito em julgado, seguir para o arquivo.

JOSUÉ ROMERO
SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO

MAVR

[1] Evento 39.

[2] Evento 45.

[3] Eventos 50 e 54, respectivamente.

[4] Tribunal Pleno – Sessão de 24/04/2024.

[5] Nesse sentido TC-023558.989.20. Tribunal Pleno – Sessão de 03/02/2021.

[6] Tribunal Pleno – Sessão de 31/10/2018.

[7] Nesse sentido, TC-005089.989.21. Tribunal Pleno - Sessão de 17/03/2021.

[8] Tribunal Pleno – Sessão de 11/06/2014.

[9] JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 1676.